

1513909-64.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciana Piovesan

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... condenando-se o réu pelo tráfico ilícito de entorpecente. A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou evidenciada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/13, pela documentação fotográfica de fls. 21, pelo auto de exibição e apreensão do entorpecente de fls. 26/27, pelo laudo de exame químico toxicológico realizado de fls. 126/129, prova técnica que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-764/765, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9053, São Paulo-SP - E-mail: sp27cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1513909-64.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162282/2022 - 24º D.P. PONTE RASA, 25566725 - 24º D.P. PONTE RASA, 2162282 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

WAGNER LUIS DA SILVA MORAES e outros

Vítima:

SAUDE PUBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

05/10/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 5 de outubro de 2022, às 18:54 horas, nesta cidade e Comarca de São Paulo, no Complexo Judiciário Criminal MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 27ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, DRA. LUCIANA PIOVESAN, comigo Assistente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência designada nestes autos. Apregoados, compareceram o(a) DD. Promotor(a) de Justiça, Dr(a). Waldir dos Reis Junior. Presente o(a) ré(u) MARCELO CARLOS DA SILVA, preso no CDP DA VILA INDEPENDÊNCIA Presente o(a) Defensor(a), o(a) Dr(a). Fernanda Corrêa da Costa Benjamim. Iniciados os trabalhos, pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Em cumprimento a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, consigno as razões pelas quais o réu permanece algemado. A movimentação de

presos neste Fórum Criminal é grande e é pequeno o número de policiais militares à disposição para a escolta e a segurança das centenas de pessoas que circulam diariamente pelo prédio, tal situação é, por si só, perigosa para a incolumidade do público, Funcionários, Advogados e Autoridades que circulam e trabalham no prédio em contato direto com os presos. Por conseguinte, a manutenção das algemas mostra-se indispensável para a segurança de todos os presentes ao ato e também daqueles que pelo prédio circulam, trata-se de medida assecuratória indispensável para que os trabalhos sejam realizados a bom termo. Em seguida, foi(ram) ouvida(s) as testemunha(s) de acusação/defesa VAGNER LUIS DA SILVA MORAES, IVAN FRANCISCO DA SILVA e PAULO JOSÉ BARRETO OLIVEIRA, conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal. Pelas partes foi expressamente manifestada desistência da oitiva da testemunha Aparecido, o que foi homologado pela MM. Juíza de Direito. A seguir, após entrevista reservada com sua defensora, foi o acusado INTERROGADO, conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal. Ato contínuo, pela MM. Juíza foi deliberado o seguinte: não havendo mais provas a serem produzidas, dou por encerrada a fase instrutória e concedo às partes a palavra para fins de apresentação de memorial. Dada a palavra ao Dr(a) Promotor de Justiça, por ele foi dito: conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal. Dada a palavra ao Dr(a) Defensor(a) Público(a), por ele(a) foi dito: MM. Juíza, Marcelo Carlos da Silva Junior foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas porque, segundo a acusação, no dia 14 de junho de 2022, por volta de 12h10, na Rua Azul da Cor do Mar, altura do numeral 08, Itaquera, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo e guardava, para o consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 80 porções de maconha, com peso líquido de 237,6g; 45 papелotes de cocaína, com peso líquido de 17,9g; 17 frascos de lança perfume, com peso líquido de 136ml; 282 pedras de crack, com peso líquido de 58,3g; 11 porções de haxixe, com peso líquido de 5,7g, substâncias proibidas e descritas como drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado, foi apresentada defesa prévia e a denúncia foi recebida. Após, o réu foi citado e foi designada audiência de instrução, debates e julgamento. Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas, interrogando-se o réu ao final. A testemunha Wagner disse não conhecer o réu, nunca o viu. Estava no dia da prisão, estava fumando maconha no campo. Foi ouvido na delegacia. Lá disse que estava fumando maconha e que tinha ido comprar. Estava esperando os meninos chegarem, ia jogar bola. Estava com outro rapaz, Juan. Questionado sobre Aparecido, disse não o conhecer. Estava usando maconha quando os policiais chegaram e mandaram deitar no chão. Eram vários policiais. Depois foram colocados na viatura e levados para a delegacia. Questionado o que disse na delegacia, se falou que tinha ido comprar droga de Marcelo, falou que não disse isso. Disse que não sabe quem estava vendendo. Na delegacia falou apenas que foi comprar maconha. Não tem receio de depor na presença do réu. Não disse em nenhum momento que foi comprar maconha com o réu. Ia comprar no local com "um menino" que vende do outro lado. Indagado quem foi na viatura junto com ele, disse que foi outro rapaz, não era o réu. não conhece esse outro rapaz que foi junto na viatura. Não sabe nem mesmo porque foi levado naquele momento. Alertado sobre o falso testemunho, disse que está falando a verdade. Foi novamente questionado se disse que compraria droga do réu, falou que não é verdade. A testemunha Ivan, policial militar, relatou que a ocorrência foi rotineira. Faziam patrulhamento em local conhecido pelo tráfico. Pediram apoio a outra equipe e entraram no local, constatando que o réu vendia drogas. Ele foi visto no canteiro do campo de futebol. Quando entraram no terreno ele estava com a droga e havia duas pessoas que iam comprar entorpecentes. Indagado se viram eles comprando, disse que eles mesmos admitiram que iam comprar. Quem estava vendendo era o réu. eles ainda não tinham comprado drogas, não havia entorpecentes com eles. Disse que o réu confessou informalmente. Com ele tinha uma pochete com todo tipo de droga em porções individuais. Tinha dinheiro também. Foram todos levados para o distrito, os três. As drogas estavam todas no estojo, na posse direta dele. Estava

tudo dentro de uma pochete e no mesmo local encontraram uma sacola. Essa sacola estava em cima de uma árvore. A pochete apenas estava com ele. Em buscas pelo local encontraram a sacola, ou melhor, ele indicou. A árvore era no local em que ele estava, ele estava embaixo da árvore. Questionado se chegaram a ver algum ato de venda, disse que não. Disse que apenas os três foram abordados, apenas eles estavam no local. Os três foram abordados pois estavam juntos. Confrontado com o fato de que na delegacia disse que a tal sacola estava nas mãos do réu, e não na árvore, a testemunha disse que estava na árvore e foi encontrada por indicação do próprio réu. Questionado sobre o que despertou suspeita para que fossem abordados apenas os três, respondeu que resolveu abordar os três porque estavam parados, juntos, em local em que há venda de drogas. A testemunha Paulo José, policial militar, disse se lembrar do acusado. Falou que faziam patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico quando avistaram o réu na venda de drogas. Outros dois indivíduos também foram abordados, eles faziam a compra. Com o réu havia uma pochete com drogas. Ele mesmo confessou que estava vendendo. O depoente estava junto com Ivan, disse que viram ele vendendo drogas. Os outros dois foram abordados no exato momento em que comprariam, o réu estava tirando drogas da pochete. Ele não chegou a entregar as drogas para os outros dois. Disse que inclusive existe uma gravação feita por equipe de televisão do momento da abordagem. Não se lembra a quantidade exata, mas havia vários tipos de droga com o réu, além de dinheiro, aproximadamente duzentos e cinquenta reais. As drogas estavam parte na pochete (estojo) e parte em uma sacola, cuja localização foi indicada por ele. Na pochete havia também dinheiro. A sacola estava em cima de uma árvore. Ele indicou onde estava e informou que era dele. Ele estava embaixo da árvore. Não é verdade o que constou de seu depoimento no DP que a sacola estava na mão dele. Quem fez a gravação foi alguém da emissora Band ou Rede TV. Viram o réu pegando a substância e fazendo o gesto de entregar para os outros dois, disse que ele vendia a droga para os outros dois. Confirmou que estavam juntos, o depoente e seu parceiro Ivan. Para pegar a sacola da árvore era preciso subir na grade do campo. A sacola não estava visível, somente com a indicação dele conseguiriam encontrar. Não havia outras pessoas no local além dos três abordados. Aproximaram-se em viatura caracterizada e viram os três. Estacionaram e fizeram a aproximação a pé. Eles tentaram fugir, mas não obtiveram êxito. De longe viram que era um gestual de venda, mas até se aproximarem não deu tempo de concluir a venda. No dia não faziam uso de câmeras no uniforme. Do matagal era possível ter visão de onde os três estavam. Viu as fotos de Wagner e Aparecido e disse que eram os dois supostos usuários. Em seu interrogatório Marcelo negou a acusação. Disse que sua mulher mora perto do campo em que foi abordado. Ia parar no campo para comprar droga quando os policiais chegaram. Eles já estavam devolvendo o troco. Chegou a comprar um pedaço de vinte reais. Era um dos outros dois que estava vendendo (Aparecido). O interrogando estava com cinquenta reais. Não é verdade que estava vendendo drogas. O Rapaz que estava com a bolsa tentou correr, mas também foi abordado, ele não conseguiu fugir. A droga estava no colo do rapaz que estava vendendo. Não sabe nada sobre droga na árvore. Ia comprar maconha. Entregou os cinquenta reais e quando ia receber o troco os policiais chegaram e ordenaram que se deitasse no chão. Conhecia os rapazes apenas de vista. Trabalha como tatuador. Mostrada a foto de fls. 33, disse que era esse que estava com a bolsa de drogas no colo. Não sabe dizer se os policiais encontraram outras drogas no local além das drogas que estavam na bolsa apreendida. Não viu se encontraram algo na árvore. Na delegacia de polícia não foi ouvido sobre os fatos. Disse não ter confessado nada em solo policial. Não foi agredido, mas pressionado para assumir, mas em momento nenhum assumiu. Passou por audiência de custódia, ocasião em que disse que não era autor dos fatos. Encerrada a instrução, tem-se que não há provas para a condenação do acusado. Preliminarmente, no caso sob análise, ausente prova da materialidade.

Isso porque não se respeitou a regra do artigo 158-B do Código de Processo Penal, sendo as drogas apreendidas em locais diversos misturadas para remessa ao Instituto de Criminalística (a que teria sido encontrada na posse direta do réu e aquela supostamente apreendida na árvore). O completo desrespeito à cadeia de custódia da prova, como se verifica no caso que ora se apresenta, compromete toda a prova dos

autos. É dizer, para que se tenha segurança e certeza acerca da materialidade de um delito, é indispensável que a cadeia de custódia da evidência seja rigorosamente observada. Caso contrário, não haverá materialidade suficiente para justificar uma condenação. É o que ocorreu no caso dos autos, pois não se sabe em relação a qual entorpecente o resultado positivo do laudo pericial diz respeito. Para se assegurar a materialidade delitiva e tentar minimizar as incertezas a respeito da existência e quantidade de entorpecentes, seria necessário registrar, de forma técnica, o material supostamente encontrado. Já no local dos fatos, há de se registrar fotograficamente onde e como a droga foi localizada e, imediatamente, efetuar o armazenamento das substâncias com lacres, sem mesclar substâncias de tipos diferentes e apreendidas em locais diversos. As normas estabelecidas no artigo 158-A e seguintes do CPP não foram minimamente respeitadas, o que vicia toda a prova do processo. O percurso da coleta da evidência até sua análise pelo perito oficial (cadeia de custódia) não pode ser influenciado por terceiros, por isso a necessidade de lacres individualizados e identificação dos objetos e substâncias. Somente as perícias realizadas com registro, rastreabilidade e integridade da prova podem ser consideradas como provas lícitas. Assim, ausente prova da materialidade, impõe-se a absolvição. Por fim, de se ressaltar que os policiais não souberam explicar o que teria motivado a abordagem do acusado, não havendo, portanto, fundadas razões que autorizassem a abordagem e a realização de busca pessoal, o que macula a prisão e toda a prova dela decorrente. Ainda que assim não se entenda, no mérito não há provas suficientes para a condenação. Os depoimentos dos policiais não podem servir de fundamento único para a condenação. Imprescindível seria a produção de prova mais robusta que comprovasse, sem deixar qualquer dúvida, que o réu estivesse traficando, o que não ocorreu no caso em tela. Repare-se que toda a prova colhida nos autos se resume ao depoimento dos agentes responsáveis pela abordagem e prisão do acusado, sem que tenha ocorrido qualquer diligência complementar na tentativa de demonstrar, com segurança, a intenção de traficância. Não se trata de negar qualquer valor ao depoimento dos agentes do Estado. Entretanto, uma condenação não pode ser baseada apenas nisso. No caso dos autos os depoimentos dos policiais, além de serem divergentes entre si divergem do que eles próprios teriam relatado em solo policial. ora, há divergências sobre se teriam os agentes públicos avistado atos típicos de venda. Há divergências, ainda, sobre o local em que foram encontradas as drogas (todas na posse direta do réu ou parte com o réu e parte em uma árvore?). No mais, a testemunha Wagner, em juízo, negou ter afirmado que iria adquirir drogas do acusado. Por fim, os policiais afirmaram que estava tudo gravado, mas a acusação sequer pleiteou a vinda das tais imagens aos autos. Assim, entendo que a negativa do réu não restou infirmada pelo conjunto probatório, sendo de rigor a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. Em caso de entendimento diverso, requer-se, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, por não se revestir a conduta de reprovabilidade maior do que a trazida pelo crime. Na segunda fase, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa. Na terceira fase, requer-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, a despeito da reincidência. De fato, deixar de aplicar a referida minorante exclusivamente em razão da recalcitrância significaria incorrer em ofensa aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. Isso porque a não aplicação da causa de diminuição acarretaria a seguinte situação: se primário, ao réu seria atribuída uma pena de 1 ano e 8 meses de reclusão; já, se reincidente, ser-lhe-ia arbitrada pena superior a 5 anos. Ora, é evidente a desproporcionalidade das sanções, atentando-se, em especial, ao fator de discriminação adotado (reincidente). Se para os demais crimes há, normalmente, em razão da reincidência, uma diferença, entre primários e reincidentes, de apenas 1/6 na pena, não há razão lógica para que apenas no tráfico se estabeleça um desnível superior a 300%. Ademais, entendendo-se pela inaplicabilidade do dispositivo acima, estaria uma mesma circunstância (reincidência) servindo, a um só tempo, como agravante e causa impeditiva da diminuição, representando, assim, duplo apenamento em flagrante infração ao princípio do non bis in idem. O regime deve ser o menos gravoso que o montante da pena permitir, observando-se o princípio da individualização da pena.

Por fim, requer seja conferido ao réu o direito de recorrer em liberdade, em homenagem ao princípio da presunção da inocência e à garantia do duplo grau de jurisdição, ambos assegurados pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica). A seguir, pela MM. Juíza de Direito foi proferida seguinte sentença: Vistos. MARCELO CARLOS DA SILVA JÚNIOR, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, segundo a denúncia, nas circunstâncias de fato ali descritas, o denunciado, trazia consigo e guardava, para o consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 80 porções de maconha, com peso líquido de 237,6g; 45 papелotes de cocaína, com peso líquido de 17,9g; 17 frascos de lança perfume, com peso líquido de 136mm; 282 pedras de crack, com peso líquido de 58,3g; 11 porções de haxixe, com peso líquido de 5.7g, substâncias proibidas e descritas como drogas, nos termos do artigo 66 da Lei 11.343/06 e Portaria SVS/MS 344/98, sendo que o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi preso em flagrante delito, e teve sua prisão convertida em preventiva, por ocasião da comunicação do flagrante ao juízo. Notificado, o réu apresentou defesa à fls. 103. A denúncia foi recebida à fls. 104 e depois foi o réu citado. O laudo de exame químico toxicológico veio às fls. 126/129. Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado. Em debates orais, o representante do Ministério Público, discorrendo sobre as provas e entendendo comprovados os fatos descritos na denúncia, pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia. A Defesa, noutro giro, arguiu preliminar de ausência de materialidade do crime e, no mérito, requereu a absolvição, a ressaltar que frágil a prova à condenação, afirmando divergentes os depoimentos dos policiais. Subsidiariamente, requereu a fixação das penas nos mínimos, o cômputo do redutor previsto em lei, no patamar máximo, em favor do acusado; com a concessão de regime mais brando para cumprimento de pena e concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é de ser julgada procedente, condenando-se o réu pelo tráfico ilícito de entorpecente. A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou evidenciada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/13, pela documentação fotográfica de fls. 21, pelo auto de exibição e apreensão do entorpecente de fls. 26/27, pelo laudo de exame químico toxicológico realizado de fls. 126/129, prova técnica que atestou serem cocaína, "maconha" e "lança-perfume", as substâncias apreendidas em poder do acusado. Observo que, neste ponto e analisando a preliminar arguida, ainda que tenham sido apreendidas todas as drogas juntas e remetidas à perícia da mesma maneira, é certo que todas elas estavam mesmo originariamente em poder do réu, como comprovado pelos depoimentos dos policiais, tendo o próprio acusado indicado onde estava o entorpecente que serviria para que praticasse o tráfico. Nesta linha, bem se tem comprovada a materialidade do crime. A autoria igualmente é certa e pode ser comprovada pela prova oral produzida em juízo. Na fase policial, o réu confessou a prática do crime. Em juízo, diferentemente, negou a prática da infração. Não mora no local dos fatos, foi até lá para visitar sua mulher. Atravessou o campo e foi comprar maconha para usar. Encontrou os dois meninos que foram abordados consigo, pediu a droga para a testemunha Aparecido, que reconhece a fls. 33. Chegou a entregar R\$ 50,00 para comprar a maconha, mas antes de receber o troco e a droga, os policiais se aproximaram e abordaram os três. A droga estava em uma pochete rosa de Aparecido. Ocorreu que os policiais falaram que era o interrogando quem estava vendendo, porque viram suas tatuagens, mas não era verdade. Foi constrangido a confessar que era o traficante. Sua negativa foi desmentida pela prova produzida. Assim porque os policiais afirmaram, em uníssono, de maneira firme e coerente, que as drogas estavam sim em poder do acusado, ao contrário do que ele quis fazer crer. Os policiais deram conta de que estavam em patrulhamento em ponto conhecido como de venda de drogas, quando visualizaram o réu no canto de um campo de futebol, embaixo da árvore, atrás da tela do tal campo, local em que há denúncias de venda de drogas. O réu estava conversando com outras duas pessoas e chegaram a perceber que o acusado estava vendendo entorpecentes, segundo o policial Paulo ele estava tirando as drogas e entregando para os outros. Os três foram abordados, dois deles admitindo que estavam ali para comprar droga

para uso, mas ainda

não o tinham feito; o réu confessando que estava vendendo. Com o acusado foi encontrado uma pochete, contendo drogas diversas, as quais reconheceram na foto de fls. 21. Ele portava dinheiro também na mesma pochete. O réu ainda indicou drogas que estavam guardadas em uma sacola em cima da árvore, embaixo da qual o denunciado estava. Somente o réu e os outros dois abordados estavam embaixo da árvore. Pois bem, diante do teor destes depoimentos, autoriza-se a condenação do réu, na medida em que tinha quantidade razoável de entorpecente e foi flagrado em atitude suspeita, com outras duas pessoas que conversavam consigo justamente no ponto conhecido como de venda de entorpecentes. Note-se que os policiais viram situação sugestiva de tráfico, já que duas pessoas conversavam com o réu, estando este com uma pochete, e estando todos eles em ponto bastante conhecido como de venda - sob árvores, ao lado de uma grade de um campo de futebol. E ainda que não se tenha por absolutamente comprovado que realizava de fato a venda de entorpecentes quando foi abordado pelos policiais, fora apreendido dinheiro em seu poder, evidenciado pela circunstância de estar na posse de porções individuais de drogas, que o entorpecente serviria, como já se frisou, ao comércio ilegal. Neste ponto, cabe ressaltar que "para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347). Plenamente amoldada, por conseguinte, a conduta do denunciado ao tipo penal cuja autoria lhe foi imputada e assim quanto mais porque é de ser ressaltado que os depoimentos dos policiais não merecem reparos quando acompanhados de outros elementos de prova - estes aqui existentes, ante as provas pericial e documental juntadas, laudo e auto de apreensão -, quando prestados em uníssono, com coerência e plena segurança, sendo esta a hipótese dos autos. Este o entendimento dominante nos Tribunais, confira-se: "O testemunho de policiais, compromissados como qualquer outra testemunha, não merece eiva de suspeição, desde que não defendam eles um interesse particular, mas o de caráter coletivo realizado pela atividade estatal" (Revisão Criminal nº 97.008463-3, da Capital. Relator Desembargador José Roberge). "TÓXICO - Tráfico - Prova de policiais - Validade - O depoimento de policiais obedece aos mesmos princípios aplicados às demais pessoas - Contradições inócorrentes - Condenação mantida" (Apelação Criminal n. 234.655-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal de Férias de "JANEIRO/98" - Relator: Passos de Freitas - 03.03.98 - V.U.). Ademais, é de ser salientado que o réu sequer conhecia os policiais e que estes tampouco conheciam o réu, de forma que não há qualquer elemento que indique que teriam interesse em incriminar injustamente uma pessoa inocente. Saliente-se que ambos os policiais destacaram que as drogas estavam com o réu, aquelas da pochete que ele portava, bem como as da sacola sobre a árvore; certo que as da árvores não estavam em suas mãos, mas sim foram por ele mesmo apontadas como estando sob sua guarda e depósito, donde inviável se repete frágil a prova produzida, não sendo verificadas as divergências apontadas pela Defesa. Assim ainda mais porque também abordados os indicados usuários, os quais foram ouvidos em delegacia, fls. 17/18, confirmando em tudo o relato dos policiais. Aliás, nesta medida é que se mostrou inverídica a narrativa da testemunha Vagner que, de maneira um tanto confusa e vaga, procurou eximir de responsabilidade o réu, apresentando versão totalmente dissonante com a do próprio acusado, afirmando que foi abordado com outra pessoa e não com o denunciado. A testemunha Vagner afirmou que não conhece o réu. Estava fumando maconha com seu amigo Juan, quando foi abordado pelos policiais. Foi para a delegacia, falaram que iam levá-lo como usuário, e lá falou que tinha droga para seu uso. Estava no local para jogar futebol, esperando os meninos com quem jogaria. Comprou droga naquele dia, lá do outro lado, pediu para a menina comprar para usar com o pessoal do "rachão". Como se vê, a versão trazida pelos policiais não pode ser abalada pelo que relata o réu, permanecendo a descrença na inverossímil exculpatória do denunciado, porque de rigor a procedência da demanda quanto ao delito de tráfico de

entorpecentes. Procedente a demanda, pelo que passo à dosimetria da pena. Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, dada a quantidade e sua natureza nociva da droga – cocaína –, a revelar elevado e devastador efeito psicotrópico, autoriza-se a fixação da pena acima do mínimo legal, vez que tais circunstâncias excedem o desvalor inerente ao tipo. Majoro a pena base em um sexto e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Relevo que a jurisprudência vem na linha do entendimento do juízo, confira-se: “A natureza nociva da substância entorpecente apreendida – cocaína – constitui fundamentação idônea a ensejar maior apenação na primeira etapa da dosimetria, pela desfavorabilidade das consequências do delito.” (HC 141092/MS). Na segunda fase, tomo em favor do réu a confissão, já que foi tomada, ainda que em pequena escala, para fundamentar esta decisão, compensando-a com a agravante da reincidência (certidões de fls. 64/66), pelo que mantenho a pena tal como fixada na base, a qual torno definitiva na ausência de outros modificadores. Faço consignar que não se aplica o artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 na espécie, dada a reincidência específica do réu, condenado que foi definitivamente pela prática de crime de mesma natureza, o que demonstra que faz de prática ao arrepio da lei o seu modo de viver. A alegação fundada na desproporção da pena não convence, por prevista a sanção em norma amplamente constitucional; não se podendo cogitar, tampouco, de bis in idem, já que o histórico criminal do réu é considerado para situações distintas aqui, na segunda e terceira fases da dosimetria, operando-se consequências jurídico-legais distintas por conta de um mesmo instituto, a fim de, justamente, individualizar-lhe a pena. Na mesma esteira, quanto à não aplicação do redutor legal para casos como o dos autos, a notável lição: “Por se tratar a redução legal específica justamente de uma atenção individualizada ao agente primário de pouco envolvimento criminoso, sua não concessão não significa piorar a situação do acusado, mas, simplesmente, não a melhorar. Nisso, sua natureza diverge diametralmente daquele aumento procedido na segunda fase dosimetria por conta da reincidência delitiva verificada. Cuida-se, no caso, de cláusula legal que se tributa, inclusive, à ideia constitucional de exata individualização da pena em favor de réus ainda estreantes na vida criminal” (TJSP, Apelação nº 0003624-48.2016.8.26.0050, São Paulo, 18 de março de 2019, SÉRGIO MAZINA MARTINS, RELATOR, v.u.). O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, dada a reincidência do acusado, a comprovação de que retira seu sustento do comércio de entorpecentes e de condutas criminosas, não tendo atingido a ressocialização, tudo a teor do que dispõe o artigo 33 do Código Penal. Ademais, considera o juízo ser o crime de tráfico ilícito de entorpecentes extremamente grave, eis que por sua conta outros tantos delitos são praticados e redes de exploração e se constituem ao seu redor. As condições do réu são modestas, de sorte que fixo no mínimo o valor de cada dia multa aplicado. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu MARCELO CARLOS DA SILVA JÚNIOR, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e à pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal. Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, à vista da reincidência e da quantidade de pena aplicada. Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que respondeu preso à imputação e foi condenado a cumprir pena em regime fechado, daí a necessidade de sua prisão para se assegure a aplicação da lei. Ademais, o réu é reincidente e estava em cumprimento de pena quando dos fatos, o que revela a necessidade de sua prisão, ainda, para que se garanta a ordem pública. Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o necessário ao cumprimento da pena. Autorizo a destruição do entorpecente apreendido, comunique-se. Declaro o perdimento das quantias em favor do FUNAD. Concedo ao réu os benefícios da assistência judiciária, isentando-o do pagamento das custas e da taxa judiciária, observado o que dispõe o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada a sentença em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se. Pela Defesa e pelo réu foi dito que interpunham recurso de apelação da decisão. Pela MM. Juíza foi deliberado: recebo o recurso interposto.

Processe-se. Abra-se vista à Defensoria para apresentação das razões e, após, ao Ministério Público para contrarrazões. Oportunamente subam os autos ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo, com as nossas homenagens. Sem prejuízo, expeça-se a guia de execução provisória. Cientes e intimados os presentes. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (MARCONDES) Assistente Judiciário, digitei, imprimi e subscrevi.

MM^a. JUIZA: assinatura digital, conforme impressão à margem direita